

1502710-09.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação.

Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1502710-09.2021.8.26.0510 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502710-09.2021.8.26.0510 - 2021/000560

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIERRY WILLIAN DOS SANTOS JUSTINO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

THIERRY WILLIAN DOS SANTOS JUSTINO, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 15h30min, na Avenida 68, entre as Avenidas 04 e 05, Jardim Araucária, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo, guardava e tinha em depósito 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido de 114,17 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24 e laudo de constatação de fls. 30/32, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 86/87).

Regularmente notificado (fls. 106), seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado (fls. 112/119), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2022 (fls. 137/144).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e uma testemunha de defesa, com posterior interrogatório do acusado (fls. 164).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da

prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, inviabilizando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da dedicação ao tráfico, devendo ser a pena cumprida em regime prisional inicial fechado, impondo-se ainda a pena de perdimento sobre a quantia apreendida em poder do acusado (fls. 164). A ilustre Defensora Pública, a sua vez, inicialmente sustentou comprometida a materialidade do delito, por derivação, assim porque ilícita a busca pessoal que resultou na apreensão do entorpecente, dada a ausência de prévia e fundada suspeita, em violação ao disposto no artigo 240, § 2º do Código de Processo Penal, a determinar a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, observando insuficiente a prova produzida, pelas razões que cuidou em expor, pugnou igualmente pela absolvição do acusado, aqui nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Assim não se entendendo, requereu a desclassificação do delito atribuído inicialmente ao acusado para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa e o reconhecimento o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Caso não aplicado o redutor, reclamou a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, com observância ao que disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, facultando-se a interposição de recurso em liberdade. Por fim, requereu a restituição dos valores apreendidos em poder do acusado (fls. 164). Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo, guardava e tinha em depósito a quantia entorpecente indicada na denúncia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no auto de exibição e apreensão de fls. 24, laudo de constatação de fls. 30/31, além do laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 91/93, com resultado positivo para cocaína.

Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida, por derivação, em função de ilícita busca pessoal realizada, dada a ausência de fundada suspeita, em afronta ao disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

Entretanto, segundo o exposto pelos Policiais Militares que participaram das diligências que resultaram na apreensão do entorpecente, na ocasião estavam em patrulhamento pela localidade -- já conhecida por ser ponto de tráfico de entorpecentes --, e por lá avistaram o acusado, que se mantinha em uma esquina, mas que, com a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e passou a andar apressadamente em direção oposta. Estas circunstâncias, constituindo fundada suspeita, que autorizava a abordagem e a busca pessoal que se seguiu, resultou efetivamente na apreensão de entorpecente com o acusado, como também nas imediações, onde ele indicou estar armazenando a substância ilícita.

Deste modo, respeitada a objeção deduzida, diante dos elementos concretamente considerados, não se entende ilícita a busca pessoal realizada, a comprometer, por derivação, a materialidade do delito.

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Ouvido em juízo, o acusado afirmou que, na ocasião, estava no local dos fatos com o propósito de adquirir entorpecente, sendo usuário. Relatou que chegou a contatar um indivíduo, tendo este se afastado para buscar a droga, ocasião em que foi abordado por Policiais Militares, com dois outros adolescentes. Naquela oportunidade, segundo o exposto, os Policiais buscavam por uma arma de fogo subtraída da corporação, exigindo que o acusado informasse a localização deste armamento e, caso assim não fizesse, iriam cumprir com o que haviam prometido, quando era menor de idade, de que quando completasse a maioridade seria preso, por isto sendo

incriminado indevidamente (fls. 164).

Todavia, a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida. De fato, os Policiais Militares ouvidos, Victor Augusto e Marco Henrique, reiterando em juízo o que inicialmente exposto, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Araucária, nesta cidade, em local conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecente, quando avistaram o acusado em uma esquina, demonstrando inquietação com a aproximação da viatura, passando a andar apressadamente em sentido contrário, razão pela qual foi realizada a abordagem, apreendendo-se com ele vinte e quatro eppendorfs contendo cocaína, além de quantia em dinheiro, indicando ainda a existência de maior quantidade de entorpecente nas proximidades, escondida em um matagal, além da origem ilícita do dinheiro. Em diligências pelo local apontado, apreenderam uma sacola contendo mais trinta eppendorfs com cocaína (fls. 164).

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, as circunstâncias indicadas não apenas revelam a posse do entorpecente, mas também a sua destinação mercantil, tendo sido o acusado abordado em local já conhecido pela realização do tráfico, de onde tentou empreender fuga, apreendendo-se em poder dele mais de duas dezenas de porções de cocaína, que ainda indicou local próximo, em um matagal, somente por isto sendo localizada quantidade ainda maior da mesma substância entorpecente, acondicionada em 420 (quatrocentas e vinte) eppendorfs, admitido, ademais, o comércio ilícito.

Assim, todos esses elementos probatórios possibilitam o acolhimento da pretensão acusatória, incidindo sobre a quantia em dinheiro apreendida a pena de perdimento porque decorrente da atividade ilícita.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, possível seja fixada a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixa-se de considerar a menoridade do acusado, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

E não há lugar para a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. É que embora o acusado seja primário, ostenta diversos registros na Vara da Infância e Juventude desta Comarca, inclusive três por atos

infracionais equiparados a tráfico ilícito de entorpecentes (processos nº 1501695-10.2018.8.26.0510, 1502612-29.2018.8.26.0510 e 1501297-29.2019.8.26.0510), já lhe tendo sido aplicada a medida socioeducativa de internação, sendo certo que, embora os registros infracionais não sejam considerados maus antecedentes, são aptos à verificação da personalidade do agente e, por aqui, também da dedicação à atividade ilícita.

Sobre isto: "Agravamento regimental em habeas corpus. Direito Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Histórico de atos infracionais. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada com tráfico de drogas. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas na via do habeas corpus para se chegar a conclusão diversa da do juízo de origem. Precedentes. Agravamento regimental não provido". (AgR HC 200302, STF. 1ª Turma. Rel: Min Dias Toffoli, julgado em 31/05/2021)

E ainda: "(...) Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravamento regimental não provido." (RHC 190434 AgR. STF. 1ª Turma. Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23/08/2021).

Assim, a dedicação à atividade ilícita, ostentando o acusado atos infracionais equiparados ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 37), além de ter sido ele abordado em local conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecente, com quantidade significativa de entorpecente, indica inequívoca reiteração e dedicação à atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, à mencionada causa especial de redução.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado THIERRY WILLIAN DOS SANTOS JUSTINO à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, e considerando a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, proferida do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênias, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênias, tenha a disposição legal violado o princípio da

individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

Sobre isto: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1). E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inocorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA